

0002298-22.2022.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS.

LIBERDADE PROVISÓRIA: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá-SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002298-22.2022.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002298-22.2022.8.26.0348

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2053572/2022 - DEL.POL.MAUA, 23225406 - DEL.POL.MAUA, 43/22/116 - DEL.POL.MAUA, 43/2022 - DEL.POL.MAUA, 2053572 - DEL.POL.MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ISAÍAS DE ALMEIDA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

MARCOS ISAÍAS DE ALMEIDA SILVA e PETERSON HENRIQUE TAMBORIM DOS SANTOS foram denunciados por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 13h30min, na Rua Topázio, 100 - Jardim Itapark, nesta cidade de Mauá, os denunciados, em concurso de agentes, expunham à venda e vendiam, para fins de tráfico, drogas ilícitas que

causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e imagens.

Recebida a denúncia, os autos principais foram desmembrados para o réu Marcos (fls.219-20). Posteriormente, o réu foi citado (fl. 259) e apresentou resposta à acusação.

O corréu Peterson foi julgado no feito principal (autos nº 1500382-79.2022.8.26.0540).

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu Marcos.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a nulidade da instrução por inobservância ao procedimento relativo ao acordo de não persecução penal. No mérito, pugna pela absolvição ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do tráfico privilegiado, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo do douto Defensor Público, a preliminar levantada não se sustenta. A questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno (fls.265-71).

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03-5), boletim de ocorrência (fls. 12-5), auto de exibição e apreensão (fls. 16-7), laudo de constatação (19-22), fotografias de fls. 39-40, laudo toxicológico definitivo (fls.170-2), além da prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial (fl.11), o réu negou a acusação, alegando ser apenas usuário de entorpecentes. Sob o contraditório, inovou. Disse que estava na "loja", ao lado do "vapor", aguardando-o entregar o dinheiro que lhe devia (mídia digital).

A versão do réu, além de contraditória, está isolada do conjunto probatório.

O policial civil Marcelo, na fase administrativa (fls.06-7), historiou que: (sic) "rumou ao sítio dos fatos, em companhia de seu parceiro, ora relacionado como policial testemunha, informando que com o fito de coibir o tráfico de entorpecentes nesta Municipalidade, deslocaram-se até a Rua Topázio, altura do numero 20 - Jd. Itapark - Mauá/SP, conhecido ponto de venda de droga, sendo que em diligências pelo local, avistaram certa movimentação de indivíduos aparentemente usuários de drogas em uma viela ali existente. Que diante disso, os policiais se posicionaram em ponto estratégico, de forma dissimulada, quando passaram a manter observação naquelas pessoas. Que após aproximadamente quinze minutos, identificaram duas pessoas, ambas de cor parda, uma de bermuda de cor bege e outra de calça de moletom camuflada, os quais estavam em atitude típica de mercancia de drogas, quais sejam, enquanto o de bermuda bege abordava as pessoas que adentravam a viela e procedia a uma rápida revista, determinando quem poderia prosseguir ou não na viela, o outro de calça de moletom, era quem recepcionava os possíveis usuários que recebia algo deles e em contrapartida entregava a possível droga. Que em momento oportuno e com apoio de

outros Policiais Civis desta Delegacia, promoveram a incursão naquela viela, quando de imediato o depoente abordou aquela pessoa na entrada da viela, seu parceiro ora relacionado como testemunha, promoveu a abordagem do outro rapaz, não deixando margem para qualquer reação ou fuga. Que tais indivíduos foram identificados como Peterson Henrique Tamborim dos Santos e Marcos Isaías de Almeida Silva, sendo que ambos, imediatamente e informalmente assumiram estarem ali na prática de tráfico de entorpecentes, sendo que Peterson receberia a quantia de oitenta reais para promover a segurança do ponto de venda de drogas enquanto que Marcos, a partir de então, passou a negar que estava ali traficando entorpecentes. Peterson alega que ali permaneceria das 21hrs do dia anterior até a parte da tarde. Que em revista pessoal nada fora encontrado na posse de ambos, no entanto, ao adentrarem a viela, o policial condutor pôde observar que Marcos se encontrava sentado em uma cadeira plástica de cor branca e na sua frente no chão, havia uma pochete de cor cinza. Ao verificar tal pochete, fora localizado no interior da mesma, as drogas ora apreendidas, além de um aparelho celular, também apreendido, sendo rechaçado por Marcos que o aparelho estivesse em sua posse, embora ele fosse o indivíduo visualizado entregando os entorpecentes aos usuários".

No mesmo sentido o depoimento do policial Vanderlei (fls.08-9).

Em juízo, o policial Marcelo reiterou que o local é conhecido como Biqueira da Laje. Na ocasião, durante patrulhamento realizado com viatura descaracterizada, visualizou uma movimentação típica de usuários de entorpecentes. Após campana de 15 minutos realizada com o uso de binóculo, ele e seu parceiro puderam avistar os suspeitos comercializando os entorpecentes. Percebeu que um deles, trajando uma bermuda bege, abordava os usuários, enquanto o segundo estava sentado em uma cadeira plástica. Chegando próximo a eles, o corréu Peterson pediu que levantasse a camisa, quando então foi abordado. Em seguida, seu parceiro abordou o réu Marcos, que estava sentado em uma cadeira e era o responsável pela venda do entorpecente. As drogas estavam na frente de Marcos, há aproximadamente um metro, armazenadas em uma pochete cinza. Na referida pochete encontraram as drogas e o dinheiro. Informalmente, Marcos alegou ser usuário e Peterson confirmou a narcotraficância. Reafirmou ter visualizado o réu Marcos praticando atos de venda (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que o depoimento prestado em juízo pelo policial militar além de plenamente coerente, está em perfeita harmonia àquele por ele prestado perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tal depoimento. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que tivesse motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu.

Além disso, quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade, o local da abordagem, conhecido como Biqueira da Laje, e a

forma em que era transportada, além do dinheiro localizado na pochete, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do réu em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da natureza das drogas apreendidas - notadamente a cocaína e o crack, de alto poder vulnerante-, fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da cocaína e do "crack" apreendidos:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Quanto a possibilidade de aumento da pena-base em razão da natureza das drogas, destaca-se julgado do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"(...) Na primeira fase, a base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e em 500 dias multa, o que será mantida ante a inércia ministerial, posto que cabível aumento em face da natureza de parte dos entorpecentes apreendidos, que somente não será levado a efeito neste momento porque vedado a reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa. Destaca-se inexistir bis in idem no uso da natureza em uma fase e a quantidade em outra. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena permaneceu inalterada. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e diminuição, a pena definitiva resultou em 05 anos de reclusão e no pagamento de 500 dias-multa. O redutor não foi reconhecido em face da quantidade e diversidade de drogas, o que não merece reparos. Foi apreendida grande quantidade de drogas, suficiente para a confecção de cerca de 105 porções individuais de cocaína e 46 de maconha, além de 43 porções de crack. A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes. Portanto, a grande quantidade, indicativa de profissionalização, demonstra que a acusada se dedica a atividades criminosas e obsta a aplicação do redutor no presente caso." (TJSP; Apelação Criminal 1500309-78.2020.8.26.0540; Des. Rel. Mens de Mello; 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/07/2021) g.n.

No mesmo sentido o e. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.

PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada. Na hipótese dos autos, não houve a incidência de bis in idem, pois, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi elevada em razão da natureza do entorpecente e, na terceira fase, o redutor previsto na Lei de Drogas não foi aplicado devido à quantidade de droga apreendida. 2. Cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las, na primeira fase, para exasperar a pena-base ou, na terceira fase, para graduar o redutor do tráfico privilegiado, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem" (AgRg no HC n. 475.345/SP, Ministro Félix Fisher, Quinta Turma, DJe 1º/3/2019). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 492.150/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 30/4/2019.) g.n.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE (ART. 44, I, CP). INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZ DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Como destacado na decisão agravada, cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las, na primeira fase, para exasperar a pena-base ou, na terceira fase, para graduar o redutor do tráfico privilegiado, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. No ponto, importa destacar que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base no patamar mínimo previsto em lei. III - A quantidade, diversidade e nocividade das drogas apreendidas podem ser utilizada para fixação do regime mais gravoso do que o quantum de pena aplicada, por configurar maior gravidade na conduta, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. Precedentes. IV - Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, não há que se falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 475.345/SP, relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.) g.n.

Na fase intermediária, tendo em vista a atenuante da menoridade relativa (20 anos - fl. 26), a pena retorna ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Em que pese o requerido pelo Ministério Público, o réu não confessou a prática do tráfico, motivo pelo qual não deve incidir tal atenuante.

Na última etapa, não deve incidir a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Diante das circunstâncias do delito, incompatíveis com traficantes "ocasionais" - o réu foi preso em flagrante com elevada quantidade de drogas, ou seja, 94 invólucros de maconha, 62 porções de cocaína, 102 microtubos de crack e 06 invólucros de skunk, atuando em compararia, em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, sabidamente dominado por facções criminosas, portanto, sem espaço para "iniciantes", além de não ter comprovado de forma mínima o exercício de atividade lícita - parece-me claro o acentuado envolvimento do acusado no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Não bastasse, o réu está preso por outro processo, em que se apura o crime de tráfico de drogas (fl. 255 - autos nº 1500937-96.2022.8.26.0540), praticado poucos meses depois do fato em comento (11.05.2022), a demonstrar que se dedica às atividades criminosas. Convém pontuar, ainda, que Marcos foi condenado naquele feito, ainda sem trânsito em julgado.

Nessa linha, posiciona-se o e Superior Tribunal de Justiça:

"CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, § 4º). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 02. "A diversidade e a quantidade de droga justificam a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado" (HC 199.227/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/04/2015; HC 315.716/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; HC 312.452/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2015). À luz desses precedentes e da premissa fática estabelecida no acórdão impugnado - o réu "trazia consigo e em momento anterior adquiriu droga, consistentes em 74,4 gramas de maconha, acondicionadas em 54 trouxinhas plásticas, e 36,07 gramas de cocaína, acondicionadas em 26 supositórios plásticos trouxinhas plásticas" -, não há como aplicar a causa de diminuição de pena do 'tráfico privilegiado' (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º). 03. Habeas corpus não conhecido"(STJ HC n. 317.721/SP Rel. Min. Newton Trisotto Quinta Turma DJe de 03/08/2015).

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça" (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.431.091 - SP (2014/0015576-0), RELATOR : MINISTRO FÉLIX FISCHER, j. 14 de dezembro de 2016).

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. AÇÕES PENAS EM CURSO. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. (...). - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que a jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que é

possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EResp n. 1.431.091/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, DJe 1º/2/2017). (...). (HABEAS CORPUS Nº 536.141 - SP (2019/0290756-9), RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, 17 de outubro de 2019)

No mesmo sentido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"(...) Embora LEONARDO seja tecnicamente primário, esse apelante ostenta outra condenação não definitiva por tráfico, delito praticado em março de 2021, cerca de cinco meses antes, portanto, do crime objeto deste feito. E, no tocante a essa condenação Processo nº 1500640-26.2021.8.26.0540 , cuja sentença foi proferida em 12 de agosto de 2021, o apelo defensivo, em julgamento realizado no dia 29 de setembro, restou desprovido pela Colenda 14ª Câmara Criminal, assim como os embargos declaratórios opostos pela Defesa também foram rejeitados em 19 de novembro do mesmo ano. Pendente de prelibação a ser efetuada pelo eminente Desembargador Presidente da Seção Criminal, o recurso especial, no caso dos autos, não impede seja a condenação por tráfico levada em consideração para afastar a pretendida causa de diminuição do privilégio em favor de LEONARDO. Trata-se, como os comparsas, de traficante não eventual, vinculado, certamente, a grupo minimamente estruturado, embora não comprovado por elementos concretos a associação de modo estável e permanente com outros indivíduos. A diversidade e a quantidade de entorpecente, para além dos registros criminais, evidenciam a habitualidade com que praticava a traficância. A conduta praticada pelos três acusados, bem como os registros criminais que ostentam, revela efetivo perigo à sociedade, denotando exacerbada culpabilidade, condição que desautoriza o reconhecimento do privilégio, benefício destinado a traficante não contumaz, de menor envergadura. (Apelação Criminal nº 1501963-66.2021.8.26.0540, Des. Rel. OTÁVIO DE ALMEIDA , j. 13.06.22).

"(...) Frise-se, por oportuno, a inaplicabilidade do redutor especial inserto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tal como decido monocraticamente. Como cediço, ao editar o mencionado dispositivo legal, o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, conseqüentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato de pequena expressão, o chamado "traficante de primeira viagem", como se pode qualificar aquele que possui "estoque" diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo. Nessa quadra, a par da primariedade, os elementos angariados aos autos demonstram, à saciedade, que as circunstâncias fáticas, concretamente recolhidas no curso das investigações e comprovadas em Juízo, são inconciliáveis com a traficância ocasional. Isso porque, o réu foi flagrado transportando e guardando exacerbada quantidade de entorpecentes (247 porções de maconha, 406 pinos de cocaína e 438 porções de crack), com naturezas extremamente destrutivas e nocivas, suficiente a atingir inúmeros usuários, de sorte a evidenciar a dedicação às atividades criminosas (narcotraficância). Nem se cogite a ocorrência do intolerável bis in idem, pois a quantidade dos entorpecentes, muito embora sopesada na primeira fase da dosimetria penal, não foi aqui considerada de forma isolada para o afastamento do benefício legal, ao contrário, as circunstâncias fáticas do flagrante policial (o que inclui natureza, quantidade e diversidade dos entorpecentes, situação de fuga à abordagem, em ponto com denúncias reiteradas da traficância), em conjunto, evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, sendo absolutamente implausível o reconhecimento do privilégio." (Apelação Criminal nº 1500603-96.2021.8.26.0540, Rel. Des. CLÁUDIA FONSECA FANUCCHI, j. 13 de dezembro de 2021).

Ainda sobre o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

"(...) Cabe salientar que 'a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas', para os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC nº 94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia). Na realidade, a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC nº 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, 'os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'. Deveras, na interpretação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 12 edição, pp. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2ª edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é, decididamente, a situação dos réus." (TJSP, Ap nº 1501840-05.2020.8.26.0540, Des. Rel. LAERTE MARRONE, j. 28.04.21).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...]" (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE

A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugênio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Estabiliza-se, assim, a sanção em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Anote-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97,256, rel. Min. Ayres Britto), bem

como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade e diversidade das drogas, assim como o alto potencial lesivo da cocaína e do crack para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. Ordem denegada.” (STF – HC 119.515/AC – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 03.12. – DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu MARCOS ISAIAS DE ALMEIDA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Faculta-se ao réu o apelo em liberdade (fls.113-37).

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defiro os benefícios da justiça gratuita (fl. 340).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA